

Konflikt interesów

Standardy – badanie – zarządzanie

Poradnik i rekomendacje
dla radców prawnych

Opracowanie dr Paweł Skuczyński

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	4
1. Zagadnienia ogólne	5
1.1. Definicja konfliktu interesów i jego podstawy normatywne	5
1.2. Po co jest konflikt interesów – funkcje instytucji	8
2. Badanie konfliktu interesów	11
2.1. Zanim zaczniemy – rejestr klientów	11
2.2. Jak metodycznie zbadać konflikt interesów	14
3. Standardy konfliktu interesów	19
3.1. Przesłanki szczególne – konfiguracje podmiotowe	19
3.2. Przesłanki ogólne – naruszenie podstawowych zasad	24
4. Zarządzanie konfliktem interesów	27
4.1. Odmowa świadczenia pomocy prawnej i wycofanie się ze sprawy	27
4.2. Uzyskanie zgody klienta	28
5. Przypisanie konfliktu interesów	31
5.1. Konflikt interesów a wspólne wykonywanie zawodu	31
5.2. Bariery informacyjne	34
Załącznik 1. Schemat badania konfliktu interesów	37

WYKAZ SKRÓTÓW

URP – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1166)

UPZ – Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 823)

KERP – Kodeks Etyki Radcy Prawnego, stanowiący załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 roku w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (t.j. załącznik do uchwały nr 884/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 roku)

KPK – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1375 ze zm.)

RWZ – Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, stanowiący załącznik do uchwały nr 124/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 grudnia 2022 roku

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1)

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJA KONFLIKTU INTERESÓW I JEGO PODSTAWY NORMATYWNE

Konflikt interesów w zawodzie radcy prawnego uregulowany jest w:

- art. 15 URP, znajdującym się w rozdziale zatytułowanym „Wykonywanie zawodu radcy prawnego”,
- art. 85 § 1–2 KPK, znajdującym się w rozdziale zatytułowanym „Obrońcy i pełnomocnicy”,
- art. 10 KERP, znajdującym się w dziale zatytułowanym „Podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego”,
- art. 26–30a KERP, znajdującym się w rozdziale zatytułowanym „Zajęcia niedopuszczalne oraz konflikt interesów”,
- § 6–7 RWZ, znajdującym się w rozdziale zatytułowanym „Konflikt interesów”.

Konflikt interesów jest zatem jedną z podstawowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Jest on funkcjonalnie powiązany z innymi podstawowymi zasadami, zwłaszcza z niezależnością radcy prawnego, ochroną tajemnicy zawodowej oraz lojalnością wobec klienta.

Ustawowa regulacja konfliktu interesów jest fragmentaryczna i ogranicza się do unormowania tylko niektórych sytuacji stanowiących konflikt. Bardziej kompleksowy charakter mają postanowienia KERP, ponieważ obejmują one całą problematykę zdefiniowania, standardów, badania oraz zarządzania konfliktem. Postanowienia RWZ stanowią uzupełnienie KERP w zakresie niektórych kwestii technicznych związanych z badaniem i zarządzaniem konfliktem interesów.

Konflikt interesów jest zdefiniowany w KERP. Jest to jednak definicja jedynie częściowa poprzez:

- określenie funkcji, którą pełni jego unikanie w systemie norm etyki zawodowej radcy prawnego (art. 10 ust. 1 KERP),
- określenie zakresu postanowień KERP, które regulują jego występowanie (art. 10 ust. 2 KERP).

Powyższa definicja ma charakter formalny, tzn. nie wskazuje, jakie kryteria należy stosować, aby daną sytuację zakwalifikować jako konflikt interesów.

Zajęcia niedopuszczalne

Konflikt interesów jest pojęciem zbliżonym, ale nietożsamym z tzw. zajęciami niedopuszczalnymi. Te ostatnie należy rozumieć raczej jako konflikt ról lub zasadę niepołączalności (*incompatibilitas*). Uregulowane są one w art. 25 i 25a KERP.

Zajęcia niedopuszczalne mają co do zasady charakter względny. Każdorazowo wymagana jest zatem ocena, czy dany **rodzaj działalności**, który zamierza podjąć radca prawny, nie narusza jednego z kryteriów wskazanych w art. 25 ust. 1 KERP, tj. czy: ???

- ograniczałaby jego niezależność,
- uchybiałaby godności zawodu,
- stwarzałaby zagrożenie dla tajemnicy zawodowej,
- powodowałaby wystąpienie konfliktu interesów.

Wśród zajęć podlegających ocenie na podstawie powyższych kryteriów jako przykładowe wymienić można:

- działalność publiczną i społeczną radcy prawnego, w tym sprawowanie różnych funkcji publicznych lub zajmowanie stanowisk w organizacjach społecznych,
- działalność zawodową i gospodarczą niebędącą świadczeniem pomocy prawnej lub niepozostającą z nią w bezpośrednim związku, w tym zatrudnienie lub sprawowanie funkcji w podmiotach gospodarczych,
- czynności pozostające w bezpośrednim związku lub podporządkowane świadczeniu pomocy prawnej jako świadczeniu głównemu.

Jeśli działalność radcy prawnego spełnia powyższe kryteria, a zatem jest dopuszczalna, to w przypadku aktywności niebędącej świadczeniem pomocy prawnej lub niepozostającej z nią w bezpośrednim związku na radcy prawnym ciąży obowiązek wyraźnego jej oddzielenia od wykonywania zawodu radcy prawnego (art. 25 ust. 3 KERP oraz § 8 RWZ).

Wśród zajęć niedopuszczalnych można wyróżnić także zajęcia bezwzględnie niedopuszczalne. Stanowią ona wyjątek od względnego charakteru omawianej zasady, uregulowane są w art. 25a KERP i obejmują:

- branie udziału lub pomaganie osobom trzecim w świadczeniu przez nie pomocy prawnej w celu zarobkowym w sposób niejawny dla klienta, szczególnie w charakterze osoby użyczającej nazwiska, cichego wspólnika lub pomocnika,
- branie udziału lub pomaganie w jakiegokolwiek formie, jakimkolwiek charakterze oraz w jakimkolwiek sposób w świadczeniu pomocy prawnej lub

prowadzeniu regulowanej działalności prawniczej przez podmioty nieuprawnione.

Zgodnie z art. 25a ust. 2 KERP, przez podmioty nieuprawnione rozumie się osoby lub podmioty świadczące pomoc prawną niezgodnie z przepisami o formach wykonywania zawodu radcy prawnego, szczególnie spółki kapitałowe lub inne osoby nieposiadające uprawnień do świadczenia pomocy prawnej.

Ponadto, radca prawny nie może wprowadzać w błąd odbiorców usług świadczonych przez osoby trzecie, w tym podmioty nieuprawnione, co do ich charakteru lub rzeczywistego pochodzenia (art. 25a ust. 3 KERP).

Ekonomiczny konflikt interesów

Do konfliktu interesów nie zalicza się sytuacji, w których świadczenie przez radcę prawnego pomocy prawnej na rzecz dwóch lub większej liczby podmiotów nie prowadzi do etycznego obowiązku jej przerwania, lecz jest niekorzystna dla któregoś z tych nich wyłącznie w sferze ekonomicznej. Do takich sytuacji należą na przykład:

- wykonywanie czynności zawodowych na rzecz klienta, który jest rynkowym konkurentem innego klienta (konflikt ekonomiczny ze względu na konkurencję),
- wykonywanie czynności zawodowych na rzecz klienta, którego stroną przeciwną jest spółka dominująca w stosunku do któregośkolwiek z klientów lub spółka zależna w stosunku do któregośkolwiek z klientów lub spółka powiązana z którymśkolwiek z klientów (konflikt ekonomiczny ze względu na powiązania holdingowe),
- wykonywanie czynności zawodowych na rzecz klienta, którego stroną przeciwną jest podmiot organizacyjnie powiązany z którymśkolwiek z klientów (konflikt ekonomiczny ze względu na powiązania koncernowe).

Należy jednak pamiętać, że w dwóch ostatnich przypadkach konflikt ekonomiczny może przekształcić się w etyczny konflikt interesów, ponieważ – zgodnie z art. 42 ust. 3 KERP – umowa z klientem należącym do grupy kapitałowej może przewidywać:

- zobowiązanie radcy prawnego do wykonywania czynności zawodowych na rzecz innych klientów należących do tej grupy, z tym że nie może to naruszać form wykonywania zawodu, ograniczać niezależności, stwarzać zagrożenia naruszenia tajemnicy zawodowej lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, uchybiać godności zawodu (art. 42 ust. 3 pkt 1 KERP),
- obowiązek brania pod uwagę przez radcę prawnego – obok interesu klienta – również interesu grupy kapitałowej, do której ten klient należy (art. 42 ust. 3 pkt 2 KERP).

Zgodnie z tym postanowieniem członkowie grupy kapitałowej, na rzecz których radca prawny jest zobowiązany świadczyć pomoc prawną, są również jego

klientami, a zatem mogą wystąpić jako strona konfliktu interesów w stosunku do będącego klientem zarówno podmiotu dominującego, jak i powiązanego, a także wobec innych klientów radcy prawnego.

1.2. PO CO JEST KONFLIKT INTERESÓW – FUNKCJE INSTYTUCJI

Zgodnie z art. 10 KERP unikanie konfliktu interesów może być traktowane jako instrument służący realizacji innych podstawowych zasad etyki zawodowej radcy prawnego, tj.:

- zapewnieniu niezależności radcy prawnego,
- dochowaniu tajemnicy zawodowej,
- lojalności wobec klienta.

Działanie w sytuacji konfliktu interesów stwarza istotne ryzyko naruszenia każdej z tych trzech zasad. Jednocześnie postanowienia KERP i RWZ powinny być interpretowane w sposób funkcjonalnie powiązany z tymi zasadami.

Jednocześnie art. 26 ust. 1 KERP, ustanawiający przesłanki ogólne konfliktu interesów, odwołuje się – choć w innej kolejności i za pomocą innych sformułowań – do tych samych zasad. Stanowi on, że radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej, jeżeli wykonywanie czynności zawodowych:

- naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia,
- ograniczałoby jego niezależność lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia,
- posiadana przez niego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę.

W konsekwencji, także na potrzeby badania konfliktu interesów, należy bliżej określić treść omawianych zasad i charakter ich związku z unikaniem konfliktu.

Niezależność

Niezależność radcy prawnego określona została m.in. w art. 7 KERP. Polega ona na tym, że radca przy wykonywaniu czynności zawodowych powinien być wolny od wszelkich wpływów wynikających z jego osobistych interesów, nacisków z zewnątrz oraz ingerencji z jakiegokolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu. Wyrażone przez kogokolwiek polecenia, ograniczające niezależność, sugestie czy wskazówki, nie mogą wpływać na prezentowane przez niego stanowisko w sprawie. Ponadto, radca prawny nie może naruszać zasad etyki zawodowej i niewłaściwie wywiązywać się z obowiązków zawodowych w celu spełnienia oczekiwań klienta lub osób trzecich (art. 7 ust. 2 i 3 KERP).

Naruszeniem niezależności mogą być więc wszelkie wpływy, interesy, naciski, polecenia, sugestie, wskazówki lub oczekiwania, które mogłyby wpłynąć na treść

lub sposób dokonywania przez radcę prawnego czynności zawodowych. Mogą one być wyrażone zarówno bezpośrednio, jak i oddziaływać w sposób dorozumiany. W każdym przypadku radca prawny nie może dopuścić, aby uzyskały one decydujący wpływ na podejmowane przez niego czynności.

Unikanie konfliktu interesów służy zabezpieczeniu przed uwikłaniem radcy w taką sytuację podmiotową, w której istniałoby znaczne ryzyko, że treść wykonywanych przez niego czynności zawodowych, a także sposób ich wykonywania byłyby determinowane nie przez względy merytoryczne, lecz przez niedopuszczalny wpływ z zewnątrz.

Należy podkreślić, że niezależność w wykonywaniu zawodu radcy prawnego jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich, demokratycznego państwa prawnego oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (art. 7 ust. 1 KERP).

Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa została uregulowana między innymi w art. 3 ust. 3 URP, zgodnie z którym radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Ponadto, należy pamiętać, że zgodnie z art. 9 KERP dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego, a także stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności.

Istotnym elementem tajemnicy zawodowej jest określenie jej zakresu. W odniesieniu do zakresu przedmiotowego zarówno ustawa, jak i KERP stanowią, że tajemnicą objęte są informacje uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej, niezależnie od ich źródła lub formy. Art. 15 ust. 3 KERP przesądza, że związek ten należy rozumieć szeroko, a zatem tajemnicą zawodową objęte są także informacje ujawnione radcy prawnemu przed podjęciem przez niego czynności zawodowych, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że ujawnienie nastąpiło dla potrzeb świadczenia pomocy prawnej i uzasadnione było oczekiwaniem, że radca prawny będzie ją świadczył. Należy brać to pod uwagę przy interpretacji przesłanki ogólnej konfliktu interesów, odnoszącej się do naruszenia tajemnicy zawodowej lub stwarzania znacznego zagrożenia jej naruszenia, o której mowa w art. 26 ust. 1 KERP.

Natomiast w odniesieniu do zakresu temporalnego zarówno ustawa w art. 3 ust. 4, jak i KERP w art. 17 przesadzają, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i istnieje również po zaprzestaniu wykonywania zawodu. *A fortiori* trwa zatem także po zaprzestaniu świadczenia pomocy prawnej. Nie obejmuje zatem jedynie informacji pozyskanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tzw. aktualnego, ale również byłego klienta. Należy podkreślić, że tym ostatnim terminem KERP się nie posługuje, ale w wielu jego postanowieniach występuje określenie „osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe” lub zbliżone. Jest ono

równoważne z terminem „były klient” i odgrywa fundamentalną rolę w unormowaniu zarówno ogólnych, jak i szczególnych przesłanek konfliktu interesów.

Na dochowanie tajemnicy zawodowej składa się wiele szczegółowych obowiązków, takich jak zakaz ujawniania informacji nią objętych, zakaz ich wykorzystania w innym celu niż w interesie klienta podczas świadczenia pomocy prawnej (art. 16 KERP), nakaz zabezpieczenia dokumentów, nośników i komunikacji (art. 23 KERP), nakaz zobowiązania współpracowników (§ 5 RWZ) itd. Dla unikania konfliktu interesów szczególnie istotny jest zakaz ustanowiony w art. 16 KERP. Zgodnie z nim dochowanie tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji i dokumentów nią objętych, ale również zakaz skorzystania z nich w interesie własnym lub innej osoby, chyba że przepisy prawa lub KERP stanowią inaczej.

Lojalność wobec klienta

Lojalność wobec klienta uregulowana jest w art. 2 URP, według którego pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana, a także w art. 8 KERP, zgodnie z którym radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Postanowienie to wprost ukierunkowuje świadczenie pomocy prawnej na interes prawny klienta, dobro klienta oraz ochronę jego praw.

Na potrzeby konfliktu interesów szczególnie istotne jest rozumienie zasady lojalności jako obowiązku wykonywania wszystkich czynności zawodowych w interesie klienta, a więc, aby osiągnąć lub zachować sytuację korzystną dla klienta.

Tak jest w przypadku pojęcia sprzeczności interesów, a więc konfliktu w sensie materialnym, którego użycie w postanowieniach KERP powoduje, że mamy do czynienia z sytuacjami konfliktu względnego. Sprzeczność interesów, polegająca na zobowiązaniu do działania w interesie określonych podmiotów, gdy realizacja interesu jednego z nich prowadzi do uszczerbku interesu drugiego, może być przynajmniej w niektórych przypadkach interpretowana jako konflikt lojalności wobec różnych klientów.

Ponadto, należy uznać, że ochronie lojalności wobec klienta służy jedna z ogólnych przesłanek konfliktu interesów, zawarta w art. 26 ust. 1 KERP, tj. wyłączająca możliwość świadczenia pomocy prawnej, gdy posiadana przez radcę prawnego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę. Oznacza to, że posiadana o danym kliencie lub byłym kliencie wiedza oraz o jego sprawach, zarówno chroniona przez tajemnicę zawodową, jak i nią nieobjęta, nie może być również wykorzystana na jego niekorzyść.

2. BADANIE KONFLIKTU INTERESÓW

2.1. ZANIM ZACZNIEMY – REJESTR KLIENTÓW

Zgodnie z art. 30a ust. 1 KERP, radca prawny przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie obowiązany jest do zbadania, czy nie występuje konflikt interesów, a w przypadku jego stwierdzenia – do odmowy jej świadczenia.

Badanie konfliktu interesów to zespół czynności intelektualnych i technicznych, mających na celu stwierdzenie, czy udzielenie pomocy prawnej klientowi wypełniłoby przesłanki konfliktu interesów uregulowane w art. 26–30 KERP.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 KERP, badanie powinno nastąpić przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Jednakże, aby je wykonać skutecznie, niezbędne jest bieżące wykonywanie rutynowych czynności przygotowawczych, polegające na gromadzeniu niezbędnych danych. Dotyczą one przede wszystkim aktualnych i byłych klientów oraz prowadzonych dla nich spraw lub wykonywanych czynności. Bez pełnej wiedzy w tym zakresie nie jest bowiem możliwe stwierdzenie z całą pewnością, czy zachodzi konflikt interesów. Jest to istotne zwłaszcza dlatego, że postanowienia KERP nie wyznaczają żadnej granicy czasowej dotyczącej badania konfliktu interesów z udziałem tzw. byłego klienta. Poleganie w tym zakresie na pamięci radcy prawnego lub przeglądaniu za każdym razem akt podręcznych nie byłoby optymalnym rozwiązaniem.

Obowiązek prowadzenia rejestru klientów

W konsekwencji § 6 RWZ nakłada na radców prawnych obowiązek prowadzenia rejestru klientów, na potrzeby badania konfliktu interesów, jako wspomniane rutynowe czynności przygotowawcze, polegające na gromadzeniu niezbędnych danych.

Postanowienie to zastrzega dodatkowo, że:

- obowiązek prowadzenia rejestru klientów nie dotyczy radców prawnych wykonujących zawód w na podstawie stosunku pracy (§ 6 ust. 1 RWZ),

- w przypadku gdy radca prawny wykonuje zawód wspólnie z innymi osobami, można prowadzić jeden rejestr klientów. Rejestr klientów jest dostępny dla wszystkich osób wspólnie wykonujących zawód (§ 6 ust. 2 RWZ).

Postanowienia RWZ dotyczące rejestru klientów zachowują daleko idącą elastyczność co do formy jego prowadzenia, zakresu danych podlegających rejestrowaniu oraz sposobu prowadzenia rejestru. Mówią one jedynie o obowiązku prowadzenia rejestru klientów na potrzeby badania konfliktu interesów. Oznacza to, że radca prawny powinien tak określić formę, treść i sposób jego prowadzenia, aby był w stanie efektywnie badać konflikt interesów i skutecznie go unikać. Decyzje dotyczące rejestru powinien więc podjąć w kontekście owych potrzeb, uwzględniając m.in. charakter swojej działalności, liczbę klientów i rodzaje prowadzonych spraw.

Forma prowadzenia rejestru

Dopuszczalna jest każda forma prowadzenia rejestru, a więc zarówno pisemna, jak i elektroniczna. Możliwe jest wykorzystywanie w tym celu:

- aplikacji do prowadzenia ksiąg rachunkowych i wystawiania faktur,
- oprogramowania do zarządzania kancelarią,
- oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami,
- rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
- zwykłego arkusza kalkulacyjnego,
- zwykłego pliku tekstowego.

Innymi słowy, za rejestr klientów może być uznana jakakolwiek baza klientów prowadzona przez radcę prawnego na inne potrzeby. Nie jest konieczna zmiana formy takiej bazy, o ile daje się ona w praktyczny sposób wykorzystać do badania konfliktu interesów. Musi więc zawierać funkcjonalną możliwość przeszukiwania jej przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, na przykład do sprawdzenia, czy przeciwnik procesowy klienta lub druga strona obsługiwanej transakcji jest lub był klientem radcy prawnego.

Dane podlegające wpisowi do rejestru

Zakres danych podlegających wpisowi do rejestru, a więc jego treść, nie jest określony przez postanowienia RWZ. Z istoty rejestru klientów wynika, że wpisane do niego dane powinny umożliwiać taką identyfikację klientów i byłych klientów, która w ramach badania konfliktu interesów pozwoli sprawdzić, czy nie występują oni na przykład w przyjmowanej sprawie w roli przeciwnika procesowego.

Minimum danych podlegających wpisowi stanowią zatem dane identyfikacyjne klienta. Z praktycznego punktu widzenia niezbędny jest taki ich dobór, aby wykluczyć możliwość pomyłki wynikającej na przykład ze zbieżności nazwiska lub nazwy (firmy), a także aby umożliwić identyfikację klienta w przypadku ich zmiany. W konsekwencji minimalny zakres rejestrowanych danych powinien być następujący.

W przypadku osób fizycznych:

- imię (imiona) i nazwisko,
- numer PESEL.

W przypadku jednostek organizacyjnych:

- nazwa (firma),
- forma prawna,
- dane rejestrowe (rodzaj rejestru, organ prowadzący rejestr, numer w rejestrze).

Nie jest niezbędne, ale zalecane zamieszczanie w rejestrze także takich danych jak:

- informacje adresowe i kontaktowe dotyczące klienta,
- oznaczenie prowadzonych dla klienta spraw lub wykonywanych czynności zawodowych,
- oznaczenie dat świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta, a zwłaszcza termin jej zakończenia.

Z punktu widzenia zasady unikania konfliktu interesów dane adresowe i kontaktowe klientów oraz byłych klientów mogą być przydatne w sytuacji, gdyby radca prawny zamierzał skorzystać z tych sposobów zarządzania konfliktem, które wymagają ich zgody.

Oznaczenie prowadzonych dla klienta spraw lub wykonywanych czynności zawodowych jest niezbędne w tych przypadkach badania konfliktu interesów, gdy postanowienia KERP wymagają stwierdzenia, czy zachodzi tożsamość lub związek spraw. Mimo to zamieszczanie w rejestrze danych o prowadzonych sprawach lub wykonywanych czynnościach na rzecz klienta nie jest konieczne, o ile radca prawny ma możliwość dokonania takiego sprawdzenia na podstawie innych źródeł, na przykład akt sprawy lub innych dokumentów. Należy uwzględnić tu praktyczną możliwość odnalezienia takich akt lub dokumentów na podstawie danych z rejestru.

Natomiast oznaczenie dat świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta, a zwłaszcza termin jej zakończenia, może być niezbędne do wypełnienia ustawowego obowiązku usunięcia danych osobowych klienta. Zagadnienie to związane jest ze sposobem prowadzenia rejestru.

Sposób prowadzenia rejestru

RWZ nie określa sposobu prowadzenia rejestru klientów. Należy zatem rekomendować, jak dokonywanie w nim wpisów oraz jego przechowywanie uczynić optymalnym.

Należy rekomendować wpisanie klienta do rejestru przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, a więc traktowanie go jako elementu innych czynności, których dokonania wymaga KERP na tym etapie relacji z klientem.

Przed przystąpieniem do świadczenia prawnej radca prawny powinien:

- zbadać, czy nie występuje konflikt interesów, a jeśli tak, to podjąć przewidziane w KERP działania (art. 30a ust. 1 KERP),
- dowiedzieć się od klienta, czy w tej samej sprawie działa lub działał już na jego rzecz inny radca prawny, a jeśli tak, to podjąć przewidziane w KERP działania (art. 53 ust. 1 KERP),
- ustalić z klientem zakres usługi, wysokość wynagrodzenia lub sposób jego wyliczenia, a także zasady ponoszenia opłat i wydatków (art. 36 ust. 1 KERP oraz art. 43 ust. 2 KERP),
- zawrzeć z klientem umowę o świadczenie pomocy prawnej (art. 43 ust. 1 KERP),
- wpisać dane klienta do rejestru klientów (§ 6 RWZ).

Techniczny sposób dokonania wpisu w rejestrze w znacznej mierze determinowany jest przez formę jego prowadzenia. W przypadku formy papierowej może to być dołączenie nowej karty do dotychczasowej dokumentacji. W przypadku formy elektronicznej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania może to być zamieszczenie nowego **rekordu** w bazie danych. Natomiast w przypadku formy elektronicznej z wykorzystaniem zwykłego arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu może to być dodanie nowego wiersza w tabeli.

Należy także pamiętać, że rejestrowanie danych klientów na potrzeby unikania konfliktu interesów jest przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego zastosowanie znajdują tu przepisy RODO w związku z art. 5a–5c URP, na gruncie których radca prawny jest administratorem danych klienta i z pewnymi **włączeniami???** ciążą na nim obowiązki z tą rolą związane. Prowadzenie rejestru klientów nie nakłada jednak na radców prawnych nowych obowiązków w tym zakresie poza tym, że dokonywanie zmian w rejestrze należy traktować jako przetwarzanie danych.

Przepisy te ustanawiają także różne okresy przechowywania danych osobowych w związku z działalnością organów samorządów zawodowych i prowadzonymi przez nie postępowaniami oraz w ramach wykonywania zawodu. W zakresie tego ostatniego przyjęto, że okres ten wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe ulegają usunięciu. Obowiązek taki spoczywa na radcy prawnym. Oznacza to, że w sposób regularny pod koniec każdego roku powinien on usuwać z rejestru, a także zgromadzone w inny sposób, dane osobowe klientów, których upłynął dziesięcioletni okres ich przechowywania.

2.2. JAK METODYCZNIE ZBADAĆ KONFLIKT INTERESÓW

Jak wspomniano, zbadanie czy nie występuje konflikt interesów powinno być dokonane przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej (art. 30a ust. 1 KERP). Pojęcie badania oznacza w tym kontekście obowiązek podjęcia w sposób

systematyczny wszelkich czynności intelektualnych i technicznych w celu zidentyfikowania sytuacji będącej konfliktem interesów w rozumieniu postanowień KERP.

Należy przy tym pamiętać, że – zgodnie z art. 30a ust 3 KERP – obowiązek unikania konfliktu interesów odnosi się również do radcy prawnego przyjmującego pełnomocnictwo substytucyjne. Na substytucie zatem również ciąży obowiązek badania konfliktu interesów.

Od badania konfliktu interesów należy odróżnić jego ujawnienie się w czasie świadczenia pomocy prawnej (art. 30a ust. 2 KERP). Może to nastąpić zarówno w sytuacji, gdy w toku wykonywania czynności zawodowych doszło do zmiany układu podmiotowego, na przykład w ramach prowadzenia danej sprawy, jak i wówczas, gdy konflikt istniał od początku, lecz z jakichś przyczyn nie został zidentyfikowany. W takich sytuacjach na radcy prawnym nie spoczywa obowiązek badania konfliktu interesów. Wymagane jest jedynie przeprowadzenie badania przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli jednak dojdzie do ujawnienia konfliktu w toku tego świadczenia, to jego skutki są takie same, jak w przypadku zidentyfikowania go poprzez badanie. Niedopuszczalne jest zignorowanie konfliktu interesów.

Aby mieć pewność, że badanie konfliktu interesów zostało przeprowadzone z należytą starannością, a więc że rzeczywiście podjęto w sposób systematyczny wszelkie niezbędne czynności, należy rekomendować podejście metodyczne. Oznacza to, że najlepszym rozwiązaniem jest zbadanie kolejno wszystkich przesłanek konfliktu interesów, uregulowanych w art. 26–30 KERP. Można w tym zakresie przyjąć różną kolejność i kierować się na przykład systematyką KERP. Jednakże poniżej zaproponowano nieco inną kolejność czynności składających się na badanie konfliktu na podstawie merytorycznego charakteru jego przesłanek oraz jego tzw. konfiguracji podmiotowych.

Przesłanki zaistnienia konfliktu interesów

Wyróżnić można dwie podstawowe grupy przesłanek konfliktu interesów, tj.:

- przesłanki ogólne (art. 26 KERP),
- przesłanki szczególne (art. 27–30 KERP).

Podczas badania konfliktu interesów pierwszeństwo należy dać przesłankom szczególnym. Dopiero, gdy żadna z przesłanek szczególnych nie zostanie spełniona, należy przystąpić do zbadania, czy nie zachodzą przesłanki ogólne.

Przesłanki szczególne dzielą się na tzw. konfiguracje podmiotowe występowania konfliktu interesów. Możemy wyróżnić cztery takie konfiguracje:

- dotyczącą interesu własnego prawnika (art. 30 KERP),
- dotyczącą interesu osób trzecich lub instytucji (art. 27 KERP),
- dotyczącą interesu aktualnego klienta (art. 28 ust. 1 i 2 KERP oraz art. 29 ust. 1 pkt. 1 KERP),
- dotyczącą interesu byłego klienta (art. 28 ust. 3 KERP oraz art. 29 ust. 1 pkt. 2 KERP).

Po ustaleniu, że nie zachodzą szczególne przesłanki konfliktu interesów, należy przejść do badania przesłanek ogólnych. Uregulowane są one w art. 26 ust. 1 KERP i – jak była już o tym mowa – odpowiadają podstawowym zasadom wykonywania zawodu, powiązanych z unikaniem konfliktu, uregulowanym w art. 10 KERP. Przesłanki te obejmują:

- naruszenie tajemnicy zawodowej lub znaczne zagrożenie jej naruszenia,
- ograniczenie niezależności radcy prawnego lub znaczne zagrożenie jej naruszenia,
- sytuację, gdy posiadana przez radcę prawnego wiedza o sprawach innego klienta lub byłego klienta, dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę.

W badaniu przesłanek szczególnych konfliktu interesu należy zwrócić uwagę na trzy istotne rozróżnienia, którymi posługują się art. 27–30 KERP.

Rodzaj czynności zawodowych

Pierwsze rozróżnienie polega na tym, że w odniesieniu do konfiguracji podmiotowych konfliktu między aktualnymi klientami oraz aktualnym i byłym klientem osobno uregulowano dwa rodzaje czynności zawodowych składających się na świadczenie pomocy prawnej. Są to:

- bycie obrońcą lub pełnomocnikiem (art. 28 KERP),
- doradzanie prawne (art. 29 KERP).

Normatywną istotą tego rozróżnienia nie jest różnica w podstawowych kryteriach, co jest konfliktem interesów w przypadku obydwu rodzajów czynności, lecz obowiązywanie dwóch rozwiązań szczególnych:

- bycie obrońcą lub pełnomocnikiem klienta jest niedopuszczalne, jeżeli przeciwnik klienta jest również jego klientem w jakiegokolwiek sprawie. Dotyczy to wyłącznie konfliktu interesów między aktualnymi klientami (art. 28 ust. 2 KERP).
- bycie doradcą klienta w sytuacji konfliktu interesów jest możliwe po uzyskaniu zgody wszystkich klientów w niej się znajdujących. Dotyczy to zarówno konfliktu interesów między aktualnymi klientami, jak i aktualnym i byłym klientem (art. 29 ust. 2 KERP).

Sprzeczność interesów

Drugie rozróżnienie polega na tym, że niektóre przesłanki konfliktu interesów wymagają jedynie stwierdzenia zaistnienia określonej sytuacji, np. układu podmiotowego, a inne wymagają dodatkowo dokonania oceny, czy zachodzi sprzeczność interesów. W konsekwencji wyróżnić można:

- bezwzględny konflikt interesów – postanowienia KERP, które nie posługują się pojęciem sprzeczności interesów,
- względny konflikt interesów – postanowienia KERP, które posługują się pojęciem sprzeczności interesów.

Pojęcie sprzeczności interesów można traktować jako konflikt w znaczeniu materialnym i odróżnić je od formalnego rozumienia konfliktu, o którym była mowa powyżej.

Sprzeczność interesów polega na tym, że w konkretnej sytuacji radca prawny jest lub może być zobowiązany do działania w interesie określonych podmiotów, a realizacja interesu jednego z nich prowadzi do uszczerbku interesu drugiego.

Pojęciem sprzecznych interesów **posługują się???** art. 28 ust. 1, art. 28 ust. 3, art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 KERP, a także art. 85 § 1 KPK. Ponadto, w art. 30 ust. 1 KERP użyto terminu „konflikt interesów”, lecz w tym kontekście należy także rozumieć je w sposób materialny. W konsekwencji, w każdym z tych przypadków do stwierdzenia konfliktu interesów niezbędna jest ocena, czy zachodzi sprzeczność interesów w materialnym sensie.

W innych przypadkach taka ocena nie jest wymagana, a do zaistnienia konfliktu interesów wystarczające jest zidentyfikowanie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w danym postanowieniu. Dotyczy to wszystkich sytuacji wymienionych w art. 27 KERP oraz art. 28 ust. 2 KERP.

Tożsamość i związek spraw

Trzecie rozróżnienie polega na tym, że co do zasady postanowienia KERP określają sytuacje konfliktu interesów, zawężając konieczność jego badania jedynie do tej samej sprawy lub sprawy z nią związanej lub nakazując szerokie podejście, mówiąc o jakiegokolwiek sprawie. Są to:

- sprawa – art. 27 pkt. 1–6 KERP,
- ta sama sprawa lub sprawa z nią związana – art. 28 ust. 1 i 3 KERP, art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 KERP,
- jakakolwiek sprawa – art. 28 ust. 2 KERP.

Gdy mowa o sprawie, należy przyjąć, że chodzi o sprawy tożsame. Tożsamość sprawy powinna być oceniana przede wszystkim pod względem formalnym, a więc jako będąca przedmiotem jednego postępowania, niezależnie od etapu, na którym się ono znajduje, toczącego się pod jedną sygnaturą.

Natomiast związek spraw należy oceniać przede wszystkim za pomocą kryteriów podmiotowych, przedmiotowych i gospodarczych, stosowanych alternatywnie. Przez kryteria podmiotowe należy rozumieć tożsamość stron postępowania w różnych sprawach, przez kryteria przedmiotowe tożsamość przedmiotu sporu lub czynu podlegającego rozpoznaniu w różnych sprawach, a przez kryteria gospodarcze realizację wspólnego celu gospodarczego w różnych sprawach.

Istotne jest podkreślenie wagi kryterium gospodarczego, zgodnie z którym nawet sprawy bez związków podmiotowych i przedmiotowych będą mogły być uznane za powiązane ze sobą. Takie sytuacje wystąpią przede wszystkim w ramach skomplikowanych relacji ekonomicznych, w których do realizacji różnych części lub etapów procesu inwestycyjnego tworzone są osobne jednostki organizacyjne, np. spółki celowe.

Osoba najbliższa

Postanowienia KERP dotyczące konfliktu interesów kilkakrotnie posługują się także pojęciem osoby najbliższej. Są to:

- art. 27 pkt 3 KERP,
- art. 27 pkt 6 KERP,
- art. 30 ust. 1 KERP.

Pojęcie osoby najbliższej jest zdefiniowane w art. 5 pkt 7 KERP, zgodnie z którym rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. STANDARDY KONFLIKTU INTERESÓW

3.1. PRZESŁANKI SZCZEGÓLNE – KONFIGURACJE PODMIOTOWE

Konfiguracja dotycząca interesu własnego prawnika

Badanie konfliktu interesów najlepiej zacząć od sprawdzenia, czy interes samego radcy prawnego nie koliduje z interesem klienta. Zagadnienia tego dotyczy art. 30 ust. 1 KERP. **Zgodnie z nim radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej klientowi, jeżeli:???**

To
powinno
być
w ciągu!

- w danej sprawie lub sprawie z nią związanej,
- pomiędzy klientem a radcą prawnym lub osobą mu najbliższą,
- istnieje konflikt interesów,
- lub znaczne ryzyko jego wystąpienia.

Należy zwrócić uwagę, że przedmiotowo postanowienie to jest zawężone do wymagania uczestniczenia w danej sprawie lub sprawie z nią związanej. Natomiast podmiotowo jest ono rozszerzone i obejmuje nie tylko radcę prawnego, ale także osobę mu najbliższą.

W postanowieniu tym mowa jest także o istnieniu konfliktu interesów lub znacznym ryzyku jego wystąpienia. Określenie to należy interpretować jako wymaganie oceny zbliżonej do występowania sprzecznych interesów w rozumieniu omówionym powyżej. Chodzi więc o niemożność realizowania interesu radcy prawnego lub osoby mu najbliższej bez uszczerbku dla interesu klienta i odwrotnie.

Należy przy tym pamiętać, że mowa jest nie tylko o realnym wystąpieniu takiej sprzeczności, ale także o potencjalnym jej zaistnieniu, ocenianym przez radcę jako znaczne ryzyko jej wystąpienia.

Dodatkowo, art. 30 ust. 2 KERP reguluje szczególną sytuację, gdy radcę prawnego i klienta wiązałyby inne relacje niż świadczenie pomocy prawnej z jednej strony lub bycie przez radcę prawnego klientem swojego klienta w ramach zwykłej działalności tego ostatniego z drugiej strony. Chodzić więc będzie nie o sytuację, gdy radca prawny na przykład dokonuje zakupów w sieci sklepów, na rzecz

której świadczy pomoc prawną. Gdyby jednak zamierzał nabyć od takiego klienta nieruchomości, wówczas mieściłoby się to w zakresie zastosowania omawianego postanowienia.

Jak mówi to postanowienie, umowa radcy prawnego z klientem, która nie dotyczy świadczenia pomocy prawnej lub nie jest zawierana w ramach zwykłej działalności klienta, powinna być poprzedzona poinformowaniem klienta o jej istotnych elementach, tak aby klient miał możliwość skorzystania z porady innego prawnika.

Konfiguracja dotycząca interesu osób trzecich lub instytucji

Jeśli konflikt interesów między radcą prawnym a klientem nie występuje, należy wówczas przejść do sprawdzenia sytuacji, o których mowa w art. 27 KERP. Według tego postanowienia, radca prawny nie może udzielić pomocy prawnej, jeżeli:

- brał udział w sprawie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub osoba pełniąca funkcję publiczną albo jako arbiter, mediator lub biegły (art. 27 pkt 1 KERP),
- zeznawał uprzednio jako świadek w sprawie o okolicznościach sprawy (art. 27 pkt 2 KERP),
- osoba najbliższa albo z jakichkolwiek przyczyn pozostająca w stosunku zależności z radcą prawnym brała lub bierze udział w rozstrzygnięciu sprawy (art. 27 pkt 3 KERP),
- sprawa dotyczy radcy prawnego, adwokata lub innej osoby, z którą radca prawny może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód, jeżeli wykonują czynności zawodowe w tym samym czasie na rzecz tego samego klienta (art. 27 pkt 4 KERP),
- był albo pozostaje w bliskich stosunkach z przeciwnikiem swojego klienta lub osobą zainteresowaną niekorzystnym dla klienta rozstrzygnięciem sprawy (art. 27 pkt 5 KERP),
- osoba najbliższa radcy prawnemu jest pełnomocnikiem strony przeciwnej lub wykonywała na jej rzecz w tej sprawie inną pomoc prawną (art. 27 pkt 6 KERP).

Postanowienie to obejmuje przypadki, gdy radca prawny, występując w roli innej niż osoby świadczącej pomoc prawną lub za pośrednictwem innej osoby, wyrobił sobie lub mógł wyrobić stosunek do sprawy lub mieć na nią wpływ, a w konsekwencji reprezentuje lub może reprezentować interes sprzeczny z interesem klienta.

Przyjmuje ono, że wystąpienie okoliczności, o których w nim mowa, w każdym przypadku w sposób bezwzględny wyklucza świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego. Nie jest więc wymagane dokonywanie jakichkolwiek ocen związanych z pojęciem sprzeczności interesów.

Postanowienie to obejmuje dwie grupy przypadków. Pierwsza to wskazane w pkt. 1 i 2 sytuacje polegające na tym, że radca prawny brał udział w sprawie jako

przedstawiciel organów władzy publicznej lub osoba pełniąca funkcję publiczną albo jako arbiter, mediator lub biegły, lub zeznawał uprzednio jako świadek w sprawie o okolicznościach sprawy.

Przez przedstawiciela organów władzy publicznej lub osobę pełniącą funkcję publiczną należy rozumieć m.in. sędziów, ławników, referendarzy, asystentów sędziów, urzędników sądowych, komorników sądowych, a także urzędników państwowych i samorządowych itp.

Udział w sprawie, o którym mowa w tym postanowieniu, należy rozumieć szeroko – nie tylko jako bezpośrednie uczestniczenie w wydaniu jakiegokolwiek rozstrzygnięcia w jej toku, ale także jako dokonywanie czynności przygotowawczych czy technicznych w ramach postępowania, a także podejmowanie czynności nadzorczych lub kontrolnych nad tokiem sprawy, choćby polegały one jedynie na zapoznaniu się z nią. Nie jest zatem udziałem w sprawie jedynie objęcie sprawy uprawnieniami nadzorczymi lub kontrolnymi, jeśli sprawując funkcję, radca prawny nie skorzystał z nich w żaden sposób. Nie jest nim również branie udziału w tworzeniu prawa znajdującego zastosowanie w sprawie ani w roli decydenta politycznego, ani legislatora lub lobbysty.

Druga grupa sytuacji, jakich dotyczy art. 27 KERP, to uregulowane w pkt. 3–6 przypadki, w których radca prawny pozostaje w określonych stosunkach z osobą, za pośrednictwem której wyrobił sobie lub mógł wyrobić stosunek do sprawy lub mieć na nią wpływ.

Jak była już o tym mowa, pojawiające się tutaj pojęcie osoby najbliższej zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 7 KERP. Ponadto, pojęcie udziału w rozstrzygnięciu sprawy, występujące w art. 27 pkt 3 KERP, należy rozumieć odmiennie od użytego w art. 27 pkt 1 KERP pojęcia udziału w sprawie. To pierwsze ma węższy charakter, co jest uzasadnione tym, że w omawianym postanowieniu nie chodzi o udział w nim samego radcy prawnego, lecz osoby jemu najbliższej.

Konfiguracja dotycząca interesu aktualnego klienta

Jeśli konflikt interesów nie zachodzi w poprzednich konfiguracjach podmiotowych, należy następnie przystąpić do zbadania, czy nie występuje on w stosunku do innego aktualnego klienta.

W tym celu należy przede wszystkim sprawdzić w rejestrze klientów, czy inne osoby będące stroną w sprawie lub w niej uczestniczące lub inne osoby będące stroną innej czynności, na przykład sporządzanej umowy, nie są już klientami radcy prawnego.

Jeśli taka sytuacja wystąpiła, należy zidentyfikować rodzaj czynności zawodowych, które mają być wykonywane na rzecz nowego klienta, tj. odpowiedzieć na pytanie, czy jest to:

- bycie obrońcą lub pełnomocnikiem,
- doradzanie prawne.

W przypadku bycia obrońcą lub pełnomocnikiem konflikt interesów między aktualnymi klientami obejmuje dwie przesłanki:

- ogólną – radca prawny nie może być obrońcą lub pełnomocnikiem klientów, jeżeli ich interesy są sprzeczne w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej (art. 28 ust. 1 KERP),
- szczególną – radca prawny nie może być obrońcą lub pełnomocnikiem klienta, jeżeli przeciwnik klienta jest również jego klientem w jakiegokolwiek sprawie (art. 28 ust. 2 KERP).

Badanie konfliktu interesów w tym zakresie należy rozpocząć od przesłanki szczególnej. W sposób bezwzględny, a więc niewymagający oceny, czy rzeczywiście zachodzi sprzeczność interesów, wyklucza ona prowadzenie sprawy przeciwko innemu klientowi, choćby wykonywało się na jego rzecz czynności w jakiegokolwiek sprawie.

Z samej logiki procesu sądowego czy innego rodzaju postępowania przed organami władzy publicznej, które co do zasady mają charakter sporny, domniemuje się w sposób niewzruszalny, że bycie przeciwnikiem procesowym wiąże się ze sprzecznością interesów. Wystarczający jest fakt pełnienia przez klientów ról przeciwników procesowych.

Jak wspomniano, w art. 28 ust. 2 KERP posłużono się pojęciem jakiegokolwiek sprawy. Oznacza to, że szczególny charakter tego postanowienia polega również na tym, że zakaz w nim wyrażony uregulowany jest w najszerszy możliwy sposób. Innymi słowy, niedozwolone jest nie tylko – co raczej oczywiste – jednocześnie reprezentowanie przeciwników procesowych w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej, ale również w zupełnie różnych, niepowiązanych ze sobą sprawach.

Następnie należy zbadać, czy nie zachodzi przesłanka ogólna omawianej konfiguracji konfliktu interesów, uregulowana w art. 28 ust. 1 KERP. Wyłącza on bycie obrońcą lub pełnomocnikiem, jeśli między klientami zachodzi sprzeczność interesów w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej.

Oznacza to, że do stwierdzenia istnienia konfliktu interesów konieczne jest nie tylko zbadanie, czy zachodzi tożsamość lub powiązanie spraw, ale również ocena, czy interesy klientów są sprzeczne.

Najbardziej charakterystyczne sytuacje na gruncie omawianej przesłanki związane są z byciem obrońcą kilku oskarżonych. Zagadnienie to jest przy tym uregulowane nie tylko przez postanowienia KERP, ale także w art. 85 KPK, którego § 1 stanowi, że obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności, a § 2 i 3 doprecyzowują, że organem właściwym do stwierdzenia istnienia sprzeczności interesów jest sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prezes sądu. Naruszenie art. 85 KPK stanowi względną przesłankę odwoławczą, a więc uchylenie orzeczenia na tej podstawie wymaga stwierdzenia również, że występowanie sprzeczności interesów mogło mieć wpływ na treść orzeczenia

(art. 438 pkt 2 KPK). Oczywiście nie zmienia to faktu, że na obrońcy kilku oskarżonych ciąży również obowiązek unikania sytuacji określonych w tym przepisie.

Na podstawie omówionego w literaturze orzecznictwa sądowego można stwierdzić, że sprzeczność interesów na gruncie art. 85 KPK, a zatem i art. 28 ust. 1 KERP obejmuje następujące sytuacje:

- sprzeczność w wyjaśnieniach składanych przez oskarżonych, nawet jeśli występuje ona między twierdzeniami ubocznymi lub z różnych etapów postępowania,
- sprzeczność w treściach wynikających z innych środków dowodowych, szczególnie z zeznań świadków lub opinii biegłych,
- sprzeczność w twierdzeniach wysuwanych we wnioskach dowodowych oraz w możliwych skutkach tych dowodów,
- sprzeczność w ocenie poszczególnych środków dowodowych oraz całokształtu materiału dowodowego,
- sprzeczność w prezentowanych poglądach na treść prawa,
- sprzeczność wynikająca z odmiennej sytuacji klientów w zakresie zastosowanych wobec nich środków zapobiegawczych.

Jeśli natomiast czynność wykonywana na rzecz nowego klienta ma polegać na szeroko rozumianym doradztwie prawnym, np. udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu opinii czy przygotowaniu projektu czynności, np. umowy, to należy zbadać, czy nie zachodzą przesłanki określone w art. 29 ust. 1 pkt 1 KERP.

Zgodnie z tym postanowieniem radca prawny nie może doradzać klientowi, którego interesy są sprzeczne z interesami innego klienta w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej. Oznacza to, że do stwierdzenia istnienia konfliktu interesów konieczne jest nie tylko zbadanie, czy zachodzi tożsamość lub powiązanie spraw, ale również ocena, czy interesy klientów są sprzeczne.

Konfiguracja dotycząca interesu byłego klienta

Jeśli konflikt interesów nie zachodzi w poprzednich konfiguracjach podmiotowych, należy przystąpić do zbadania, czy nie występuje on w stosunku do byłego klienta.

W tym celu ponownie należy posłużyć się danymi z rejestru klientów, czy inne osoby będące stroną w sprawie lub w niej uczestniczące lub inne osoby będące stroną czynności, w której radca prawny doradza, np. sporządzanej umowy, nie były wcześniej klientami radcy prawnego.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy ponownie zidentyfikować rodzaj czynności zawodowych, które mają być wykonywane na rzecz nowego klienta, tj. odpowiedzieć na pytanie, czy jest to:

- bycie obrońcą lub pełnomocnikiem,
- doradztwo prawne.

Badanie konfliktu interesów w omawianej konfiguracji jest jednak o tyle prostsze od konfiguracji konfliktu między aktualnymi klientami, że brak jest przesłanek szczególnych. Ponadto, podobnie jak poprzednio, przesłanki konfliktu w przypadku bycia obrońcą lub pełnomocnikiem oraz doradztwa prawnego uregulowane są w podobny sposób, a główna różnica między nimi polega na dopuszczalnych sposobach zarządzania konfliktem. Zagadnienie to zostanie omówione w dalszej części.

W przypadku bycia obrońcą lub pełnomocnikiem konflikt interesów między aktualnym i byłym klientem uregulowany jest w art. 28 ust. 3 KERP, zgodnie z którym radca prawny nie może być obrońcą lub pełnomocnikiem klienta, którego interesy są sprzeczne z interesami osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej. Oznacza to konieczność zbadania, czy zachodzi tożsamość lub powiązanie spraw, a także ocena, czy interesy klientów są sprzeczne.

W przypadku doradzania klientowi zastosowanie znajduje art. 29 ust. 1 pkt 2 KERP, według którego radca prawny nie może doradzać klientowi, jeżeli jego interesy są sprzeczne w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej z interesami osoby, na rzecz której radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe. Tutaj również niezbędne jest zatem zarówno zbadanie, czy zachodzi tożsamość lub powiązanie spraw, jak i ocena, czy interesy klientów są sprzeczne.

3.2. PRZESŁANKI OGÓLNE – NARUSZENIE PODSTAWOWYCH ZASAD

Jak już kilkakrotnie wspomniano, przesłanki ogólne konfliktu interesów uregulowane są w art. 26 ust. 1 KERP. Obejmują one trzy powiązane z podstawowymi zasadami wykonywania zawodu sytuacje, w których:

- wykonywanie czynności zawodowych naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia,
- wykonywanie czynności zawodowych ograniczałoby niezależność radcy prawnego lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia,
- posiadana przez radcę prawnego wiedza o sprawach innego aktualnego lub byłego klienta dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę.

Naruszenie tajemnicy zawodowej

Pierwszą ogólną przesłanką konfliktu interesów jest sytuacja, w której wykonywanie czynności zawodowych naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia.

Jak już była o tym mowa, na dochowanie tajemnicy zawodowej składa się wiele szczegółowych obowiązków. Z punktu widzenia konfliktu interesów najważniejszy wydaje się obowiązek uregulowany w art. 16 KERP, tj. zakaz skorzystania z informacji objętych tajemnicą zawodową w interesie własnym lub innej osoby, chyba że przepisy prawa lub KERP stanowią inaczej.

Omawiana przesłanka konfliktu interesów będzie zatem spełniona, jeśli nie zachodzi on na podstawie jednej z przesłanek szczególnych, np. ze względu na brak tożsamości lub związku spraw albo materialnie rozumianej sprzeczności interesów, a mimo to może dojść do wykorzystania informacji objętych tajemnicą zawodową dla korzyści własnej radcy prawnego lub jego klienta.

Wykorzystanie informacji objętych tajemnicą zachodzi, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu takiej informacji i używa jej, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, składniki mienia, których ta informacja dotyczy.

Ograniczenie niezależności

Drugą ogólną przesłanką konfliktu interesów jest sytuacja, gdy wykonywanie czynności zawodowych ograniczałoby niezależność radcy prawnego lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia.

Jak już wspomniano, naruszeniem niezależności mogą być wszelkie wpływy, interesy, naciski, polecenia, sugestie, wskazówki lub oczekiwania, które mogłyby wpłynąć na treść lub sposób dokonywania przez radcę prawnego czynności zawodowych. Mogą one być wyrażone zarówno bezpośrednio, jak i oddziaływać w sposób dorozumiany. W żadnym przypadku radca prawny nie może dopuścić, aby uzyskały one decydujący wpływ na podejmowane przez niego czynności.

Konfliktem interesów na podstawie omawianej przesłanki będą więc takie sytuacje, gdy podejmowane przez radcę prawnego czynności zawodowe zarówno co do treści, jak i sposobu ich dokonywania byłyby determinowane przez niedopuszczalny wpływ z zewnątrz z pominięciem względów merytorycznych. Źródłem tego wpływu może być na przykład silna zależność ekonomiczna lub innego rodzaju od klienta lub osób trzecich, która w pewnym układzie podmiotowym może rodzić pokusę oddziaływania na radcę prawnego co do zajmowanego w sprawie stanowiska. Ryzyko takie należy minimalizować, odmawiając przyjęcia sprawy ze względu na konflikt interesów.

Nieuzasadniona przewaga

Trzecią ogólną przesłanką konfliktu interesów jest sytuacja, w której posiadana przez radcę prawnego wiedza o sprawach innego aktualnego lub byłego klienta dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę.

Przesłankę tę należy interpretować jako obejmującą te naruszenia zasady lojalności wobec klienta, które nie są ani sprzecznością interesów w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej, ani naruszeniem tajemnicy zawodowej. Dochodzi w nich jednak do wykorzystania wiedzy o danym kliencie lub byłym kliencie oraz o jego sprawach na jego niekorzyść.

Mogą to być sytuacje, w których radca prawny obsługiwał przez długi czas przedsiębiorcę i nabył w ten sposób szeroką wiedzę o sposobie jego zorganizowania i przebiegu procesów zarządczych. Następnie reprezentuje on oso-

by fizyczne będące konsumentami w sprawach przeciwko temu przedsiębiorcy, będącemu wówczas jego byłym klientem. Sprawy te nie są jednak tymi samymi lub powiązanymi ze sprawami, w których brał udział, obsługując przedsiębiorcę. Oceny jednak wymaga, czy wiedza o tym jak przedsiębiorca funkcjonuje nie daje nieuzasadnionej przewagi konsumentom reprezentowanym przez radcę prawnego.

4. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

4.1. ODMOWA ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ I WYCOFANIE SIĘ ZE SPRAWY

Jak była już o tym mowa, należy odróżnić:

- zidentyfikowanie konfliktu interesów wskutek jego badania przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej,
- ujawnienie się konfliktu interesów w toku świadczenia pomocy prawnej.

W obydwu przypadkach skutki są takie same i polegają na tym, że świadczenie pomocy prawnej w danej sprawie jest niedopuszczalne, jednakże wymagany od radcy prawnego sposób postępowania jest nieco inny.

Odmowa świadczenia pomocy prawnej

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 KERP, radca prawny przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie obowiązany jest do zbadania, czy nie występuje konflikt interesów, a w przypadku jego stwierdzenia – do odmowy jej świadczenia.

Ponadto, § 9 ust. 1 RWZ stanowi, że radcy prawnemu nie wolno zawrzeć umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, która ogranicza jego niezależność, narusza tajemnicę zawodową lub zagraża jej naruszeniu, powoduje powstanie konfliktu interesów lub uchybia godności zawodu, a § 19 ust. 2 pkt 3 RWZ stanowi, że celem lub skutkiem umowy o świadczenie pomocy prawnej nie może być m.in. wystąpienie konfliktu interesów.

Odmowa świadczenia pomocy prawnej w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów jest zatem obligatoryjna. Konflikt jest więc jednym z ważnych powodów odmowy udzielenia pomocy prawnej w rozumieniu art. 22 ust. 1 URP.

Obowiązek odmowy świadczenia pomocy prawnej dotyczy jedynie osoby, która o nią do radcy prawnego się zwraca. Konflikt nie wpływa zatem na możliwość dalszego świadczenia pomocy prawnej na rzecz dotychczasowego klienta, którego interesy były sprzeczne z interesami zgłaszającego się klienta.

Nie jest wprost wymagane, lecz rekomendowane poinformowanie takiej osoby o przyczynach odmowy, jednakże z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Rezygnacja ze świadczenia pomocy prawnej

Bardziej złożona jest sytuacja, o której mowa w art. 30a ust. 2 KERP, stanowiącym, że jeżeli konflikt interesów ujawni się w czasie świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie, radca prawny obowiązany jest z niej zrezygnować i wypowiedzieć pełnomocnictwo wszystkim klientom, których dotyczy konflikt interesów.

Ujawnienie konfliktu w czasie świadczenia pomocy prawnej może nastąpić zarówno wskutek zmiany układu podmiotowego w toku wykonywania czynności zawodowych, na przykład w ramach prowadzenia danej sprawy, jak i wskutek błędnego lub opartego na niepełnych danych badania konfliktu, przeprowadzonego przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Obowiązek zrezygnowania ze sprawy polega na wyłączeniu się ze sprawy i wypowiedzeniu klientowi pełnomocnictwa. Jeśli ujawniony konflikt dotyczy co najmniej dwóch aktualnych klientów, wówczas obowiązek wyłączenia się radcy prawnego dotyczy każdego z nich. Jest tak nawet wówczas, gdy współpraca z jednym z nich miała charakter stały, a z drugim jedynie incydentalny. Radca prawny nie może w takiej sytuacji dokonać wyboru klienta, na rzecz którego chciałby nadal świadczyć pomoc prawną. Oznaczałoby to bowiem wyraźne preferowanie interesu jednego z nich. Z tego względu jeszcze większego znaczenia nabiera wstępne badanie konfliktu interesów.

W tym przypadku również nie jest wprost wymagane, lecz rekomendowane poinformowanie klienta lub klientów o przyczynach zrezygnowania ze świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie.

Należy pamiętać, że do wyłączenia się ze sprawy ze względu na konflikt interesów ma zastosowanie art. 22 ust. 2 URP, zgodnie z którym radca prawny, wypowiadając pełnomocnictwo, umowę-zlecenie lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw.

Obowiązek ten dookreślony jest przez art. 47 KERP, według którego radca prawny, rezygnując ze świadczenia pomocy prawnej, obowiązany jest uczynić to w takim czasie, aby klient w celu ochrony swoich interesów mógł skorzystać z pomocy prawnej innej osoby. W takim przypadku radca prawny obowiązany jest dokonać czynności niecierpiących zwłoki, których zaniechanie wiązałoby się z nieodwracalnym uszczerbkiem dla interesu klienta.

4.2. UZYSKANIE ZGODY KLIENTA

Obowiązki odmowy oraz rezygnacji ze świadczenia pomocy prawnej mogą zostać wyłączone poprzez uzyskanie zgody klientów. Jest to rozwiązanie szcze-

gólne, o wąskim zakresie zastosowania. Zgodnie z art. 29 ust. 2 KERP, możliwość taka dotyczy bowiem jedynie zakazów doradzania, o których mowa art. 29 ust. 1 KERP, z zastrzeżeniem, że radca prawny nie może jednak uzyskać takiej zgody, jeżeli jest lub był obrońcą w sprawie karnej co najmniej jednego z klientów.

Na zakres zastosowania zgody jako sposobu zarządzania konfliktem interesów składają się zatem następujące okoliczności:

- radca prawny jedynie doradza klientom, których interesy są sprzeczne w danej sprawie lub w sprawie z nią związanej, a nie jest w niej obrońcą lub pełnomocnikiem któregoś z nich,
- radca prawny jedynie doradza klientowi, którego interesy są sprzeczne z interesem byłego klienta w danej sprawie lub w sprawie z nią związanej, a nie jest i nie był obrońcą żadnego z klientów w jakiegokolwiek sprawie.

Zgoda klienta została zdefiniowana w art. 5 pkt 9 KERP i ma zastosowanie w wielu sytuacjach w nim uregulowanych, a zatem nie tylko w odniesieniu do konfliktu interesów. Przez pojęcie zgody klienta rozumie się wyrażone przez klienta oświadczenie o akceptacji określonego sposobu działania lub zaniechania przez radcę prawnego w toku świadczenia pomocy prawnej, złożone po poinformowaniu klienta o okolicznościach stanowiących istotę danego działania lub zaniechania, jego skutkach, zagrożeniach z nim związanych oraz możliwych bądź wyłączonych przez taką zgodę działaniach alternatywnych.

Rozwiązania KERP opierają się na koncepcji tzw. świadomej zgody. Jednym z jej podstawowych celów jest poszerzenie i zabezpieczenie autonomii klienta, a więc – najogólniej rzecz biorąc – sytuacji, w której jest on podmiotem, a nie przedmiotem w relacji z radcą prawnym. Uzyskiwanie zgody klienta jest zatem rozwiązaniem służącym temu, aby kluczowe decyzje dotyczące prowadzenia sprawy były podejmowane przez niego samodzielnie, a nie jednostronnie przez prawnika. Jednocześnie, aby wyrównać wszelkiego rodzaju faktyczną przewagę tego ostatniego, wynikającą z reguły z większej wiedzy i doświadczenia, zgoda ta ma być w pełni świadoma, a więc poprzedzona wyczerpującym poinformowaniem klienta o istocie i skutkach tej decyzji, a także upewnieniu się, że są one dla niego zrozumiałe.

W konsekwencji uzyskanie zgody na gruncie KERP musi być poprzedzone poinformowaniem klienta o:

- okolicznościach stanowiących istotę danego działania lub zaniechania,
- jego skutkach,
- zagrożeniach z nim związanych,
- możliwych bądź wyłączonych przez zgodę działaniach alternatywnych.

W przypadku konfliktu interesów należy zatem klienta poinformować co najmniej o:

- okolicznościach – zidentyfikowanym konflikcie interesów i jego źródłach,

- skutkach – akceptacji przez klienta działania radcy prawnego w sytuacji konfliktu interesów,
- zagrożeniach – potencjalnym uszczerbku dla interesu klienta,
- działaniach alternatywnych – odmowie lub rezygnacji ze świadczenia pomocy prawnej.

Postanowienia KERP nie przewidują żadnej szczególnej formy wyrażenia zgody przez klienta. Może być ona zatem złożona także w formie ustanej. Jednak w przypadku konfliktu interesów należy rekomendować odebranie jej przez radcę prawnego co najmniej w formie dokumentowej.

5. PRZYPISANIE KONFLIKTU INTERESÓW

5.1. KONFLIKT INTERESÓW A WSPÓLNE WYKONYWANIE ZAWODU

Zagadnienie konfliktu interesów w ramach form wspólnego wykonywania zawodu zostało uregulowane w art. 26a KERP. Ustanawia on tzw. zasadę przypisania konfliktu. Polega ona na tym, że jeśli w ramach takiej formy wykonywania zawodu jedna osoba znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, to pozostałe osoby również traktuje się tak, jakby znajdowały się w takiej sytuacji. Przypisuje się więc im konflikt. Można także powiedzieć, że osoba taka zaraża konfliktem pozostałe.

Zasada przypisania ustanowiona jest w art. 26a ust. 1 KERP, według którego radca prawny obowiązany jest powstrzymać się od czynności zawodowych w sprawie ze względu na konflikt interesów lub znaczne ryzyko jego wystąpienia, jeśli wykonuje zawód w kancelarii wspólnie z innymi radcami prawnymi lub osobami, z którymi na podstawie przepisów prawa może wspólnie wykonywać zawód i ktokolwiek z nich znajduje się w sytuacji konfliktu interesów.

Zakres zasady przypisania

Zakres zastosowania zasady przypisania konfliktu interesów jest wyznaczany przez dwa elementy. Po pierwsze, powyższe postanowienie mówi o wykonywaniu zawodu wspólnie w kancelarii z innymi osobami. W tym kontekście przez kancelarię należy rozumieć każdą organizacyjno-prawną formę wykonywania zawodu radcy prawnego, przewidzianą w URP (art. 5 pkt 5 KERP). Na gruncie URP zagadnienia tego dotyczy art. 8 ust. 1. Choć nie posługuje się on wprost tym podziałem, to należy przyjąć, że ujęte w nim formy wykonywania zawodu radcy prawnego dzielą się na:

- indywidualne formy wykonywania zawodu,
- wspólne formy wykonywania zawodu.

Indywidualne formy wykonywania zawodu to umowa cywilnoprawna oraz kancelaria radcy prawnego. Przesądza o tym § 2 pkt 6 RWZ, stanowiąc, że przez kancelarię radcy prawnego rozumie się formę wykonywania zawodu we własnym

imieniu i na własny rachunek przez radcę prawnego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Wspólne formy wykonywania zawodu to spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1–3 URP, a więc spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna, w której odpowiednio wspólnikami, partnerami lub komplementariuszami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów UPZ.

Wykonywanie zawodu w stosunku pracy może być zarówno indywidualną, jak i wspólną formą wykonywania zawodu w zależności od tego, czy w danej jednostce organizacyjnej zatrudniony jest jeden czy więcej radców prawnych.

Po drugie, omawiane postanowienie dotyczy wspólnego wykonywania zawodu z innymi radcami prawnymi lub osobami, z którymi na podstawie przepisów prawa może wspólnie wykonywać zawód. Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 6 KERP i należy przez nie rozumieć osobę, która – zgodnie z przepisami URP – może być wspólnikiem spółki, w której radca prawny wykonuje zawód. W konsekwencji zastosowanie znajduje tu art. 8 ust. 1 URP, a zatem takimi osobami są adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów UPZ.

Należy zatem uznać, że przypisanie radcy prawnemu konfliktu interesów będzie zachodziło:

- w zespole radców prawnych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, gdy w sytuacji konfliktu znajduje się inny radca,
- w spółce, gdy w sytuacji konfliktu znajduje się inny radca, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy lub prawnik zagraniczny wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów UPZ.

Standardy konfliktu interesów

Ponieważ osoby wspólnie wykonujące zawód mogą być członkami różnych zawodów, może powstać sytuacja, w której będą one związane różnymi zasadami dotyczącymi konfliktu interesów. Wynika to z tego, że są one adresatami różnych kodeksów etyki zawodowej, przyjmowanymi w ramach właściwego samorządu.

Powstaje wówczas sytuacja zbiegu norm etyki zawodowej. Jego rozstrzygnięcie nie wynika wprost z postanowień KERP, ale rekomendować należy przyjęcie w tym zakresie zasady wyższego standardu. Oznacza to, że w przypadku, gdy do danej sytuacji stosują się postanowienia KERP oraz kodeksu etyki zawodowej innego zawodu, to w ramach wspólnego wykonywania zawodu należy zastosować ten z nich, w którym przyjęte jest bardziej restrykcyjnie podejście.

Rozwiązanie takie ma dwie najważniejsze zalety. Po pierwsze, w sytuacji, gdy jako mający wyższy standard zostanie zastosowany inny kodeks etyki zawodowej niż wynikający z KERP, to ten ostatni i tak zostanie spełniony jako mniej wymagający. Etyka zawodowa radcy prawnego nie zostanie naruszona. Po drugie, podejście pozwalające w ramach wspólnego wykonywania zawodu stosować

osobom niebędącym radcami prawnymi niższe niż w KERP standardy konfliktu interesów, prowadziłyby do zaakceptowania sytuacji, w których osoba wykonująca inny zawód mogłaby podjąć się świadczenia pomocy prawnej, podczas gdy w odniesieniu do radcy prawnego byłoby to niedopuszczalne. Na zasadzie przypisania radca prawny zarażałby więc pozostałe osoby wspólnie wykonujące zawód, ale inna osoba stosująca niższy standard nie zidentyfikowałaby tej samej sytuacji jako konfliktu i nie doszłoby do przypisania konfliktu pozostałym osobom. Tworzyłoby to wyraźną lukę.

Procedura badania konfliktu interesów

Przypisanie konfliktu interesów rodzi także wiele problemów praktycznych w zakresie badania konfliktu interesów. Ogólnie należy przyjąć, że przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej badanie konfliktu należy wykonać oddzielnie w stosunku do każdej osoby wspólnie wykonującej zawód. Jeśli wynik badania będzie pozytywny w stosunku do jednej z tych osób, to należy wszystkich traktować jako znajdujących się w sytuacji konfliktu.

Badanie takie będzie znacznie ułatwione, jeśli osoby wspólnie wykonujące zawód zdecydują się prowadzić wspólny rejestr klientów. Zgodnie z § 6 ust. 2 RWZ, jeżeli radca prawny wykonuje zawód wspólnie z innymi osobami, można prowadzić jeden rejestr klientów, dostępny dla wszystkich osób wspólnie wykonujących zawód. Wystarczające jest wówczas jednokrotne sprawdzenie w rejestrze aktualnych i byłych klientów, zamiast osobnego badania w odniesieniu do każdej osoby wspólnie wykonującej zawód.

Należy jednak pamiętać, że badanie konfliktu interesów za pomocą danych z rejestru obejmuje jedynie dwie jego konfiguracje podmiotowe, tj. między aktualnymi klientami oraz między aktualnym i byłym klientem. Nie dotyczy ono dwóch pozostałych konfiguracji, tj. z udziałem interesu samego radcy prawnego oraz generowanego za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji. Może również zdarzyć się sytuacja, że źródłem konfliktu będzie świadczenie pomocy prawnej przez jedną z osób wspólnie wykonujących zawód na przykład jeszcze przed założeniem spółki lub wstąpieniem do niej.

Dlatego należy rekomendować, aby w każdym przypadku badania konfliktu interesów w ramach wspólnych form wykonywania zawodu obejmowało ono nie tylko sprawdzenie danych w rejestrze lub rejestrach klientów, ale także zapytanie za pomocą wewnętrznych środków komunikacji wszystkich osób wykonujących wspólnie zawód, czy nie dostrzegają konfliktu związanego wyłącznie z okolicznościami ich dotyczącymi, na przykład zainteresowania w wyniku sprawy lub braniu w niej wcześniej udziału w innej roli niż świadczenie pomocy prawnej.

Dołączenie do wspólnej formy wykonywania zawodu

Szczególnym przypadkiem z punktu widzenia unikania konfliktu interesów jest dołączenie nowej osoby do wspólnej formy wykonywania zawodu, na przykład

wejście radcy prawnego do spółki świadczącej pomoc prawną. Taka osoba z reguły ma swoją historię spraw, która może mieć wpływ na zaistnienie konfliktu interesów na zasadzie jego przypisania.

Rekomendować należy, aby w przypadku dołączenia nowej osoby do wspólnej formy wykonywania zawodu przeprowadzić badanie konfliktu interesów:

- pełne – obejmujące zarówno byłych, jak i aktualnych klientów – jeśli w chwili dołączenia osoba ta świadczy na rzecz kogokolwiek pomoc prawną,
- ograniczone – obejmujące byłych klientów – jeśli w chwili dołączenia osoba ta nie świadczy żadnej pomocy prawnej.

Pozytywny wynik badania konfliktu w takich przypadkach może spowodować konieczność wycofania się ze świadczenia pomocy prawnej na rzecz określonych podmiotów zarówno ze strony wszystkich wspólnie wykonujących zawód, jak i osoby dołączającej. Uprzednie przeprowadzenie badania może więc być kluczowe na przykład dla odłożenia dołączenia w czasie w celu dokończenia postępowań lub czynności będących źródłem konfliktu, o ile nie wchodzi w grę uzdrawiające sytuację sposoby nim zarządzania.

5.2. BARIERY INFORMACYJNE

Zagadnienie zarządzania konfliktem interesów w sytuacji jego przypisania w pewnym zakresie podlega zasadom ogólnym, a w pewnym zakresie znajdują do niego rozwiązania szczególne.

Przed wszystkim należy zauważyć, że zasada przypisania stoi na przeszkodzie przekazaniu sprawy przez osobę dotkniętą konfliktem interesów innej osobie wspólnie wykonującej zawód. Jej istotą jest bowiem, że wszystkie takie osoby należy traktować jakby znajdowały się w sytuacji konfliktu.

Możliwe jest natomiast zastosowanie sposobów zarządzania konfliktem na zasadach ogólnych, a więc przede wszystkim uzyskanie zgody klientów, o której mowa w art. 29 ust. 2 KERP. Skoro bowiem po uzyskaniu zgody możliwe jest doradzanie klientom przez jednego radcę prawnego w sytuacji sprzecznych interesów w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej, to tym bardziej należy dopuścić taką możliwość, gdy klientom doradzałyby dwie lub więcej osób wspólnie wykonujących zawód.

Ponadto, w art. 26a ust. 2 KERP przewidziano szczególny sposób zarządzania konfliktem interesów w warunkach jego przypisania. Zgodnie z nim radca prawny może świadczyć pomoc prawną w przypadku przypisania konfliktu wyłącznie za zgodą klienta lub osoby, na rzecz której uprzednio wykonywał czynności zawodowe oraz jeżeli przyjęte w kancelarii rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają ochronę tajemnicy zawodowej, a posiadana przez radcę prawnego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, nie daje nieuzasadnionej przewagi. Możliwość taka wyłączona jest w sytuacjach, o których mowa w art. 28 ust. 2 KERP.

Zastosowanie barier informacyjnych

Rozwiązanie to można określić jako bariery informacyjne, a bywa nazywane także chińskimi murami.

Zgodnie z tym, co powiedziano powyżej, może znaleźć ono zastosowanie, gdy przypisany konflikt interesów:

- dotyczy uprzedniego zaangażowania radcy prawnego w sprawie w roli innej niż świadczenie pomocy prawnej lub powstał za pośrednictwem osoby trzeciej – art. 27 KERP,
- dotyczy interesu własnego radcy prawnego – art. 30 KERP,
- dotyczy bycia obrońcą lub pełnomocnikiem aktualnych klientów o sprzecznych interesach w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej – art. 28 ust. 1 KERP,
- dotyczy bycia obrońcą lub pełnomocnikiem aktualnego klienta o sprzecznych interesach z byłym klientem w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej – art. 28 ust. 2 KERP.

Bariery informacyjne nie znajdują natomiast zastosowania, gdy przypisany konflikt interesów:

- dotyczy bycia obrońcą lub pełnomocnikiem klientów będących przeciwnikami procesowymi w jakiegokolwiek sprawie – art. 28 ust. 2 KERP – na mocy wyłączenia w art. 26a ust. 2 KERP,
- dotyczy doradzania aktualnym klientom, których interesy są sprzeczne w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej – art. 29 ust. 1 pkt 1 KERP – na mocy dopuszczenia w art. 29 ust. 2 KERP,
- dotyczy doradzania aktualnemu klientowi, którego interesy są sprzeczne z interesem byłego klienta w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej – art. 29 ust. 1 pkt 2 KERP – na mocy dopuszczenia w art. 29 ust. 2 KERP.

Poza wskazaniem konfiguracji podmiotowych, w których bariery informacyjne mogą znaleźć zastosowanie, postanowienia KERP i RWZ formułują także warunki, które muszą być spełnione, aby było to możliwe w konkretnej sytuacji. **Niezbędne jest przeprowadzenie następujących czynności???** w rekomendowanej poniżej kolejności:

- **posiadanie???** uprzednio opracowanej w formie pisemnej i przyjętej polityki barier informacyjnych, uwzględniającej zasady określone w § 7 ust. 1 RWZ i dostosowującej je do charakteru i warunków świadczonej pomocy prawnej (§ 7 ust. 1 RWZ),
- wyznaczenie radcy prawnego lub innej osoby do prowadzenia sprawy lub wykonywania czynności oraz sprawdzenie, czy posiadana przez niego wiedza o sprawach innego klienta lub byłego klienta dotkniętego konfliktem nie daje klientowi w tej sprawie lub czynnościach nieuzasadnionej przewagi (art. 26a ust. 2 KERP),

- uzyskanie zgody klienta lub byłego klienta na taki sposób zarządzania konfliktem interesów, połączone z poinformowaniem go o treści polityki barier informacyjnych (art. 26a ust. 2 KERP),
- zapewnienie rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę tajemnicy zawodowej, określonych w polityce barier informacyjnych w sposób dostosowany do okoliczności świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sytuacji (art. 26a ust. 2) KERP.

Polityka barier informacyjnych

Zgodnie z § 7 ust. 1 RWZ, polityka barier informacyjnych powinna być opracowana w ramach wspólnego wykonywania zawodu, jeżeli radca prawny zamierza zarządzać konfliktem interesów poprzez stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 26a ust. 2 KERP.

Polityka barier informacyjnych nie jest więc obligatoryjna. Jednakże bez jej opracowania i przyjęcia nie jest możliwe korzystanie z barier informacyjnych jako sposobu zarządzania konfliktem interesów.

Opracowanie i przyjęcie polityki barier informacyjnych nie jest tożsame z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których ona dotyczy. Wdrożenie powinno nastąpić dopiero w odniesieniu do konkretnej sytuacji, po wyznaczeniu osoby wspólnie wykonującej zawód nią objętej oraz po uzyskaniu zgody klienta lub byłego klienta.

Polityka barier informacyjnych powinna uwzględniać co najmniej następujące zasady i dostosować je do charakteru i warunków świadczonej pomocy prawnej:

- sprawdzenie, czy radca prawny przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie miał dostępu do informacji objętych tajemnicą zawodową lub dających temu klientowi nieuzasadnioną przewagę w stosunku do innego podmiotu pozostającego w konflikcie interesów (§ 7 ust. 1 pkt 1 RWZ),
- zapewnienie, że radca prawny podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie ma dostępu do takich informacji (§ 7 ust. 1 pkt 2 RWZ),
- zapewnienie, że radca prawny podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie kontaktuje się w tych sprawach z osobami zatrudnionymi w kancelarii lub z nią współpracującymi, które zapoznały się z takimi informacjami lub mają do nich dostęp (§ 7 ust. 1 pkt 3 RWZ),
- zapewnienie, że radca prawny podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie korzysta z pomocy oraz nie współpracuje z osobami, które zapoznały się z takimi informacjami lub mają do nich dostęp (§ 7 ust. 1 pkt 4 RWZ).

Zgodnie z § 7 ust. 2 RWZ zasady te mogą być realizowane poprzez:

- uniemożliwienie radcy prawnemu dostępu do dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową lub dające klientowi nieuzasadnioną przewagę w stosunku do innego podmiotu pozostającego w konflikcie interesów (§ 7 ust. 2 pkt 1 RWZ),
- ograniczenie radcy prawnemu dostępu do systemów informatycznych kancelarii w zakresie umożliwiającym zapoznanie się z takimi informacjami (§ 7 ust. 2 pkt 2 RWZ),
- świadczenie przez radcę prawnego pomocy prawnej wyłącznie w odrębnym lokalu niż główny lokal kancelarii (§ 7 ust. 2 pkt 3 RWZ),
- objęcie powyższymi działaniami osób, z których pomocy radca prawny korzysta lub z którymi współpracuje, szczególnie personelu biurowego (§ 7 ust. 2 pkt 4 RWZ).

Załącznik 1. Schemat badania konfliktu interesów

Paweł Skuczyński jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Jest również prezesem fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej, a także zastępcą redaktora naczelnego „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”. Opublikował m.in. „Status etyki prawniczej” (2010, wyd. ang. 2013), „Etykę adwokatów i radców prawnych” (2016) oraz, wspólnie z Karolem Muszyńskim, „Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych” (2020).